Lección 1: La administración pública y el Derecho administrativo - Pepe Ribera

1. El concepto de Derecho administrativo
    A) Tesis o conceptuaciones objetivas
        Derecho administrativo como Derecho de los servicios públicos: Leon Duguit, Gaston Jézé
        Derecho administrativo como Derecho de las prerrogativas o poderes exorbitantes de la administración: Maurice Hauriou
    B) Tesis o Conceptualización subjetiva (Eduardo García de Enterría): algunas ideas de partida sobre la noción de administración pública
2. Características del Derecho administrativo
    A) Es Derecho público
    B) Imposibilidad de codificación
    C) Es un Derecho con dos vertientes o “bifronte”
        Regula el ejercicio de potestades por parte de la administración pública
        Define un régimen protector del ciudadano ante la actividad de la administración
    D) Aplicado por un orden jurisdiccional especializado: contencioso-administrativo
3. Relaciones del Derecho administrativo con otros sectores del ordenamiento jurídico
    A) Derecho internacional
    B) Derecho de la Unión Europea
    C) Derecho constitucional
    D) Derecho civil
    E) Derecho mercantil
    F) Derecho penal
    G) Derecho del trabajo
    H) Derecho financiero y tributario
    I) Derecho de la Seguridad Social
4. Surgimiento y evolución histórica
    A) Derecho surgido de las revoluciones liberales: la Revolución Francesa
    B) Recepción en España: Constitución de Cádiz de 1812
    C) Desarrollo carente de sistematización institucional hasta la segunda mitad del siglo XX
    D) La construcción dogmática e institucional del Derecho administrativo: la generación de la postguerra
    E) La Constitución de 1978
    F) La entrada de España en la hoy llamada Unión Europea
    G) La situación actual

5. El ámbito de aplicación del Derecho administrativo
La administración no solo aplica DA
El DA no solo lo aplican las administraciones públicas, sino que lo aplican otras instancias tanto públicas como privadas
La “huida del derecho administrativo”

1. El concepto de Derecho administrativo

Históricamente ha habido 2 grandes tesis definitorias del derecho administrativo. Aunque alguna de ellas hoy está en desuso.

Sector del ordenamiento jurídico que regula las diversas estructuras operativas de que dispone el Estado para llevar a cabo las tareas administrativas que le encomiendan la Constitución y las Leyes.

Según **Santamaría Pastor**, el destinatario primario de una buena parte de las normas que se integran en el Derecho Administrativo es el ciudadano.

A) Tesis o conceptuaciones objetivas

Las tesis objetivas definen el Derecho administrativo partiendo de su objeto, sobre la base del **objeto** del Derecho administrativo.

Las tesis objetivas se caracterizan porque definen el Derecho administrativo respondiendo a la pregunta: **Qué regula el derecho administrativo?**

Aparecen en primer lugar. Hay 2 grandes escuelas.

Derecho administrativo como Derecho de los servicios públicos: Leon Duguit, Gaston Jézé

Escuela de **Burdeos**, y fundamentalmente su representante fue **Leon Duguit**. **Finales** del **s. XIX** y **principios** del **XX**.

Lo que caracteriza a la administración es que presta servicios públicos (todo aquello que hace la administración para Duguit) en sentido amplio y que será Derecho administrativo esa rama del derecho que regula este tipo de servicio.

Inconveniente: no existe una definición clara de qué es el servicio público. Ni siquiera hoy se sabe qué es el servicio público. Por lo tanto la definición es **insuficiente**.

Ej de servicio público en sentido estricto:

- Se considera que el saneamiento de aguas residuales es un servicio público. Antes de devolver el agua al cauze, hay que limpiarlas y hacer que no sean nocivas para el medio ambiente. Hace 30 años no se pensaba que esto podría ser un servicio público hoy en día.

- Hasta 1996, los servicios de telefonía se consideraban servicio público (Telefónica). Hoy en día hay muchas compañías privadas.

Derecho administrativo como Derecho de las prerrogativas o poderes exorbitantes de la administración: Maurice Hauriou

Escuela de **Toulouse**, y fundamentalmente su representante fue **Maurice Hauriou**.

Entienden que el derecho otorga a la administración una serie de potestades exorbitantes para que pueda cumplir sus funciones. Estos autores ponen el acento en el hecho de que para que la administración pueda cumplir sus funciones, es necesario que esa administración tenga reconocidos una serie de poderes exorbitantes: potestades que no tenemos los ciudadanos.

Entonces lo que caracterizaría al derecho administrativo sería que regula esas potestades o poderes exorbitantes.

Cuando hablamos de potestad exorbitante nos referimos al **imperium**

Ej actuales:

Potestad sancionadora.

Potestad normativa. → la administración dicta reglamentos

Los impuestos.

Expropiación.

Inconveniente: es un hecho evidente que la administración hace infinidad de cosas que no se basa en una potestad exorbitante. Ej: dar una subvención, cualquier servicio social, servicios sanitarios (no hay ejercicio de autoridad), prestación educativa de nivel superior

▼ **¿No son compatibles estas 2 grandes escuelas?**

Tesis subjetiva.

Ambas tesis (objetivas) tienen la **misma insuficiencia** → no tenemos unos perfiles claros del objeto del derecho administrativo.

Aunque historicamente surgieron en primer lugar, hoy en día están abandonadas como tesis puras.

Ante sus carencias, surge la tesis subjetiva.

B) Tesis o Conceptualización subjetiva (Eduardo García de Enterría): algunas ideas de partida sobre la noción de administración pública

Está totalmente consolidada. Debida a **García de Enterría**. Temporalmente surge en los años 50 y 60 del s. XX. Hoy en día nadie la discute.

Define el Derecho administrativo con arreglo a su sujeto y nos dice: el derecho administrativo es aquel derecho que regula a la administración pública tanto en su estructura y funcionamiento interno como con sus relaciones con terceros. Mientras lo regula la administración pública, es Derecho público.

El Derecho administrativo es aquel que regula la administración pública en:

- Su **vertiente interna**: estructura y funcionamiento interno de las administraciones públicas. Ej: normas que distribuyen las normas por los ministerios.
- Su **vertiente externa**: relaciones con el exterior, con terceros. Ej: cuando nos sancionan, esto son relaciones externas con su exterior.

Cuando surge la tesis subjetiva, **todavía hoy hay autores que hacen matizes basados en conceptos objetivos.**

2. Características del Derecho administrativo

A) Es Derecho público

Es el **Derecho público por excelencia**.

Es derecho público porque **regula a un poder público**. Los poderes públicos son el **legislativo**, el **ejecutivo** y el **judicial**. El Derecho administrativo es aquel que regula el poder ejecutivo. Éste poder está en la cúspide de la administración pública.

En muchos países no se habla de Derecho administrativo, se habla de Derecho público y ya.

B) Imposibilidad de codificación

Es imposible reconducir el Derecho Administrativo a una única o a unas pocas normas jurídicas.

1. Esta codificación no es posible porque la **administración pública interviene en prácticamente todos los ámbitos de la vida**. Cualquier cosa está marcada por la intervención de la administración en sectores muy distintos, y por tanto requieren regulaciones específicas.

   Hay muchísimas normas.

   Cuando pone código de derecho administrativo, esto es mentira.

2. También, hay **pluralidad de fuentes administrativas**. Crea derecho administrativo:

   a. Legislador estatal

   b. Legiladores autonómicos

   c. Administración estatal

   d. Administraciones autonómicas

   e. Adminstraciones locales (que hay más de 8000)

   Estructura marcadamente "**multinivel**" y de particular **complejidad**.

c. Por su **ridmo de modificación** → está sujeto a un nivel de variación elevadísimo. No hay día en que se publique un diario oficial en la que no haya cientos de modificaciones del Derecho administrativo.

   Se dice que la legislación de Derecho administrativo está *motorizada*.

   ***incesante mutabilidad*, extraordinaria extensión**

*****Preponderancia de la norma escrita**

C) Es un Derecho con dos vertientes o "bifronte"

**Característica principal.

Regula el ejercicio de potestades por parte de la administración pública

Por una parte, es una rama del derecho que disciplina la actividad de la administración → el Derecho administrativo es el derecho que nos dice **qué** puede hacer la administración y **cómo** puede hacerlo.

Por lo tanto, la **administración sólo puede hacer aquello que el ordenamiento jurídico le permite hacer**. Y además, cuando la administración lleva a cabo sus **funciounes, las tiene que ejercer como el derecho administrativo le dice.**

Por lo tanto, el Derecho administrativo **legitima la acción de la administración**. No hay acción legítima de la administración si no está dentro de los parámetros del Derecho administrativo.

Privilegios singulares a la Administración **"de carácter exorbitante"**.

Define un régimen protector del ciudadano ante la actividad de la administración

Es una rama del derecho **garantista para el ciudadano.** Al limitar la acción de la administración, protege al ciudadano. Tiene un **carácter instrumental** respecto a los fines públicos que persigue y en beneficio indirecto de la ciudadanía.

- **Protección *ex ante***: con carácter previo. Antes de que la administración tome sus decisiones.

  La Administración no puede tomar decisiones de manera aleatoria. Hay que llevar un **procedimiento administrativo**, y se ha de permitir al presunto infractor que ponga pruebas, alegaciones, audiencia,…. posibilidad de que se defienda.

  Ej: tráfico. "Si usted no hace alegaciones, sólo se tendrá que dictar la resolución final" *Te puedes defender, tienes ése derecho.

- **Protección *ex post***: a posteriori. Después de que la administración ha tomado sus decisiones que nos afecta.

  Se materializa en el **derecho de los ciudadanos de impugnar/recurrir las decisiones administrativas** (tanto en vía administrativa - para que la administración tenga la ocasión de reconsiderar su decision → es un **recurso administrativo**, como en vía judicial - ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo → es un **recurso contencioso-administrativo** [cuando está "contencioso", estamos en ámbito judicial]).

  - Vía administrativa → recurso administrativo
  - Vía judicial → recurso contencioso-administrativo

En los últimos años, cada vez es menor el papel de derecho administrativo como garantista para el ciudadano y mayor el papel de legitimación de la acción de la administración. Se va ***erosionando***.

Toda la crisis económica (2008 - 2014) y toda la legislación derivada de la pandemia ha afavorecido esto. *Se puede cambiar desde el poder legislativo, que busquen proteger más al ciudadano.

Las dos vertientes mencionadas están **presentes de manera ostensible en las instituciones centrales del Derecho Administrativo**: el acto administrativo, el servicio público, los bienes públicos, las sanciones administrativas, la expropiación forzosa, etc.

Está presidido por la **tensión** entre estas dos vertientes y la búsqueda de un **equilibrio** adecuado entre ambas.

D) Aplicado por un orden jurisdiccional especializado: contencioso-administrativo

Hay **5 órdenes jurisdiccionales**, **4 ordinarios** y **especializados** en distintas materias:

- jurisdicción **civil**
- jurisdicción **penal**
- jurisdicción **contencioso-administrativa**
- jurisdicción **social** o **laboral**

y **1 especial**: el **militar**.

Siempre que hay un conflicto con la administración y ese conflicto es de Derecho administrativo, dicho conflicto lo va a resolver la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Lo que podemos afirmar es que la adm. pública está sujeta al control judicial de un órden jurisdiccional especializado (contencioso-administrativo).

**Ahora mismo hay un colapso en el Tribunal Supremo, hay muchos vacantes. Y ésto afecta sobretodo a la sala 3a (contencioso-administrativo) → qué interés hay en que pase esto? quien controla al gobierno es la sala 3a del Tribunal Supremo. Cuanto más débil sea esta sala, menos control.

El nivel inferior está en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y su instancia superior en el **Tribunal Supremo (Sala Tercera)**

▼ **¿Qué sala del tribunal supremo trata asuntos administrativos?**

La sala 3a.

3. Relaciones del Derecho administrativo con otros sectores del ordenamiento jurídico

Lo de las diversas materias sirven para las facultades de derecho, pero en realidad todas las ramas del derecho están mezcladas. Unas ramas del derecho **condicionan a las otras**. Y el derecho administrativo no es la excepción, no es un derecho más importante que los otros.

A) Derecho internacional

B) Derecho de la Unión Europea

C) Derecho constitucional

La **constitución reserva derechos** del ciudadano frente al poder público. También **define el modelo de Estado.**

Al Derecho Administrativo corresponde el **desarrollo** y pormenorización de las aludidas opciones constitucionales, que proporcionan a las **Administraciones el marco de referencia fundamental en el que han de desenvolverse**, tanto en los aspectos organizativos o estructurales, como en el encauzamiento de su actividad.

D) Derecho civil

Las instituciones básicas son las del derecho civil. Cuando hablamos de contrato administrativo, hablamos de “contrato”, que ya es civil.

Las instituciones del derecho civil se trasladan al derecho administrativo y siempre adaptadas.

E) Derecho mercantil

Las Administraciones públicas pueden crear sociedades mercantiles. SA, SL, … sociedades de capital. Estas sociedades de capital creadas por la administración se someten al derecho mercantil.

F) Derecho penal

Sobretodo en materia de derecho sancionador se relacionan el derecho penal y el administrativo. **Los principios del derecho penal y administrativo sancionador son comunes.**

G) Derecho del trabajo

Normalmente la gente habla de funcionario. En el ámbito del **empleo público hay muchas tipologías de personal**. Hay funcionarios, que se rígen íntegramente de DA, pero también hay personal laboral, que se rige por el derecho de trabajo aunque en muchos aspectos se rige por el derecho administrativo.

El profe es funcionario, pero la conserge es personal laboral. El profe tiene un derecho íntegramente de DA, y ella tiene un régimen mixto.

Hay algunas ramas del derecho que no es que guarden relación con el DA, sino que **son derecho administrativo puro y duro**. Son manifestaciones del DA → sobretodo 2:

H) Derecho financiero y tributario

1. **Derecho tributario**: se separa del DA únicamente por **razones académicas**. Se dijo que era una asignatura distinta. Pero materialmente es DA. No hay jurisdicción de tributario, hay jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

I) Derecho de la Seguridad Social

2. **Derecho de la Seguridad Social**: se encardina en la órbita del derecho de trabajo a **efectos académicos.**

4. Surgimiento y evolución histórica

A) Derecho surgido de las revoluciones liberales: la Revolución Francesa

El Derecho administrativo moderno es fruto de las revoluciones liberales (rev. industrial británica, rev. americana y rev. francesa), sobretodo en la **Revolución Francesa**.

Esta revolución supone le paso del **Estado Absoluto** al **Estado liberal**.

En el Estado absoluto, se entiende que el poder es de **origen divino** y que Diós ejerce el poder en la tierra a través de los reyes y el papa. Si el poder es de origen divino, éste el ilimitado. Por lo tanto no hace falta derecho administrativo.

En la Revolución Francesa dicen que el poder no es de origen divino. El poder pertenece al pueblo. → le cortamos la cabeza al rey porque nos estaba tomando el pelo ya que su poder no era ilimitado. **Montesquiev** → idean la Revolución. **División de poderes**: el poder pertenece al pueblo pero será un caos, por lo tanto el pueblo tiene que delegar el poder. Y no sólo a un poder, sino a **varios poderes** para que unos se controlen a los otros y ésto evite los abusos de poder. Entonce se crea el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Tenemos un **poder ejecutivo** que **no es de origen divino** y que además se ejerce por **delegación**. Aunque el pueblo haya cedido, el titular es el pueblo, y por lo tanto es necesario un derecho (1) que regule el ejercicio del poder del ejecutivo y (2) que proteja al ciudadano frente a posibles excesos o abusos de poder. Así es cómo surge el derecho administrativo.

▼ **¿Qué poder representa al Derecho Administrativo?**

El poder ejecutivo.

Contexto del ***constitucionalismo liberal***.

Principios:

- ***Separación de poderes.***
- ***Unidad*** en la organización administrativa.
- ***Igualdad*** de los ciudadanos.

Se trata de una consolidación del **Estado de Derecho** → ***derechos de los ciudadanos consagrados constitucionalmente - principio de legalidad*** → ***control de las AAPP.***

B) Recepción en España: Constitución de Cádiz de 1812

1. **Cortes y Constitución de Cádiz de 1812:** Es un derecho de **origen francés**. Esta constitución implanta un modelo político de inspiración francesa (centralizado) y un modelo de administración también de inspiración francesa.

Ese modelo implantado se vió sometido a contínuos vaivenes marcados por los distintos periodos de la historia de España. Tras su implantación, cómo evoluciona su diseño?

2. **Regencia de María Cristina de Borbón (1833):** *Consejo de Ministros y Ministerios → creación del Ministerio de Fomento.*
3. **"Década moderada" (1844 - 1854):** *Primera regulación de la jurisdicción contencioso-administrativa.*
4. **Último cuarto del siglo XIX:** *Ley de Expropiación Forzosa de 1879, Ley de Bases del procedimiento administrativo de 1889.*
5. **Primeras décadas siglo XX:** *Ley General sobre funcionarios públicos de 1918.*
6. **Años 50:** *"la década prodigiosa" → Expropiación Forzosa de 1954.*

C) Desarrollo carente de sistematización institucional hasta la segunda mitad del siglo XX

La **consolidación dogmática** del DA se produce a partir de los años 50 del siglo XX. *Hasta ese periodo, había una proliferación de legislación administrativa*, pero era:

- Una legislación muy fragmentaria y dispersa. "*la selva del derecho administrativo*". No obedece a un patrón.
- **Una legislación carente de una definición de sus instituciones fundamentales**: el legislador iba dictando leyes "sin ton ni son".

D) La construcción dogmática e institucional del Derecho administrativo: la generación de la postguerra

A partir de los años 50 del siglo XX (dictadura de Franco) se lleva a cabo la construcción de esas instituciones. Por qué en este periodo? aparece una generación de administrativistas que se preocupa de llevar a cabo esa construcción. Ej: **García de Enterría**, Alejandro Nieto, Jesús González Pérez,….

Se empieza a hablar sobre el procedimiento administrativo. A hablar también de revisión de oficio.

E) La Constitución de 1978

Supone una auténtica revolución para el DA por varios motivos:

1. **La Constitución implanta un nuevo modelo de Estado** → pasamos de un estado centralizado a un descentralizado. Pasamos de un Estado con un único creador de derecho (el Estado) a un Estado con miles creadores de derecho: Estado, CCAA, … Supone un gran incremento cuantitativo del DA.

2. **Por primera vez en el derecho español se introduce un estatuto jurídico del ciudadano en una norma constitucional.** Está en el Título 1o de la Constitución → están todos los derechos y deberes constitucionales y dentro de ellos, los derechos fundamentales y libertades públicas.

   Se trata, en definitiva, del reconocimiento de posiciones activas (de poder → derechos), frente a la administración.

Por tanto, la CE refuerza el papel del DA como derecho protector del ciudadano frente al poder público.

Posterior a la Constitución, destaca la ***Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (1998).***

También destaca la **creación de un Tribunal Constitucional.**

F) La entrada de España en la hoy llamada Unión Europea

En **1986** España ingresa en la entonces Comunidad Europea que hoy es la **Unión Europea**. Ésto supone la aparición de una nueva fuente material de un nuevo creador de DA (la UE).

Derecho de la Unión Europea que vincula/condiciona al legislador español.

¿El derecho de la Unión Europea vincula al legislador español? ¿Cómo lo vincula?

La UE, en tanto que poder público, **crea fundamentalmente DA.**

1. La immensa mayoría de la normativa que sale del parlamento europeo y de la comisión es DA.

2. La mayor parte del DA español está condicionada por normas de la UE. Ej: la UE tiene una carta de derechos fundamentales del ciudadano europeo. → todo el derecho ambiental deriva del derecho de la UE.

Por tanto, el DA hoy en día está claramente marcado por el derecho de la Unión.

Ha sido una **expansión progresiva**, una ***reconfiguración*** del Derecho Administrativo español. Se ha ido consolidando un **Derecho Administrativo Europeo.**

G) La situación actual

Tras la entrada de España en la UE suceden muchas cosas, **¿qué sucede hoy en día?**

Hoy en día estamos experimentando un cierto **debilitamiento del papel del DA como derecho protector del ciudadano** frente al poder público. Ésto lo podemos ver en 2 períodos de crisis:

1. Crisis económica 2008 - 2014.
2. Crisis del Covid.

El legislador se ha preocupado menos por el derecho de los ciudadanos y más por los de la administración.

Per fer la conclusió, pàg 61 manual.

Por tanto, puede hablarse de una **relativa modernidad del Derecho Administrativo.**

MARTÍN-RETORTILLO → *no puede hablarse de Derecho Administrativo hasta que no existe Administración Pública.*

España, antes de 1812, en muchos casos se sitúa en un nivel avanzado en comparación con otros países en la época respectiva. También en las *regulaciones relativas las materias que hoy en día regula el DA* es posible encontrar prolongadas líneas evolutivas.

5. El ámbito de aplicación del Derecho administrativo

Es una rama del derecho que regula las administraciones públicas.

Sin embargo, ***las AAPP no se rigen sólo por el DA y, por otra parte, éste se aplica en ocasiones a entidades que no tienen la condición de AP.***

Tenemos que tener en cuenta **2 matices:**

La administración no solo aplica DA

▼ **¿Puede la Administración aplicar otro derecho que no sea el administrativo?**

Sí, por ejemplo en materia de contratos, en la compraventa o en materia laboral.

Hay muchos ámbitos en que la administración actúa aplicando ramas del derecho distintas al DA. Hay ámbitos en que la propia norma remite a estas otras ramas del derecho. Hay ámbitos que dice que en este caso la admin. se regirá por el Derecho Civil.

Ej: ***materia de contratos*** - los contratos privados de la administración. Se caracterizan porque en su preparación y adjudicación se rigen por el derecho administrativo pero en su ejecución y extinción se rigen por el derecho civil. Ej: ***compraventa de un immueble*** - es un contrato privado. Cuando la administración compra un immueble lo hace aplicando el derecho civil. Pero cuando lo hace comprando bienes muebles, se rige por el DA - sería un contrato de suministro.

Hay ocasiones en que la admin. actua sujeta al derecho privado.

Posibilidad de que las AAPP creen entidades con forma privada de personificación. Hay **tres tipos** de situaciones de especial significación:

1. **Contratos "privados" de las entidades públicas:** los contratos públicos se distinguen entre:
   a. *Administrativos*: su contenido viene impuesto por las Directivas sobre contratación pública de la UE.
   b. *Privados*: la regulación sustantiva de la relación contractual se somete a las normas de Derecho Privado.
2. **Bienes de "dominio privado" de las AAPP:** hay bienes →
   a. De *dominio público.*
   b. De *dominio privado*: no están destinados a un uso público ni a un servicio público. Se someten a las normas de Derecho privado.

      El Derecho Privado penetra con fuerza en el régimen del dominio privado de las AAPP.
3. **Personal laboral de la Administración: la aplicación del Derecho Laboral a una parte significativa de los empleados públicos:** hay personal *funcionario* y personal *laboral.* Hay diferencias en materia de acceso al empleo público y en lo relativo al régimen disciplinario.

Las eventuales controversias que se susciten en esta relación de empleo entre Administración y personal laboral se resuleven con carácter general por la jurisdicción social.

El DA no solo lo aplican las administraciones públicas, sino que lo aplican otras instancias tanto públicas como privadas

Hay determinadas **INSTANCIAS PÚBLICAS** que, a pesar de no ser admin. pública, aplican derecho administrativo. Ej: las universidades públicas. Des del 2015, tienen negada la condición de admin. pública. Tienen toda la forma de admin. pública pero no lo son. Y aún así aplican derecho administrativo.

▼ **¿Las universidades públicas son administraciones públicas?**

Des del 2015 no, pero tienen toda la forma de administración pública y aún así aplican derecho administrativo.

Hay otras instancias que aplican DA → ej: administración de justicia. No se refiere a dictar sentencias, sino al gobierno de lo judicial. Al nombramiento de jueces, ascenso de jueces, contratación del poder judicial, … pero el CGPJ no es admin. pública. El Tribunal Constitucional no son admin. pública, es un órgano Constitucional. Pero todos ellos aplican derecho administrativo.

▼ **¿El CGPJ y el Tribunal Constitucional son administración pública?**

No, pero aplican derecho administrativo.

a. Inicialmente, se pivotava en torno al concepto de ***Administraciones Públicas***.

b. La tendencia va hacia utilizar el concepto de ***Sector Público*** → **alcance más ámplio** que el de AP. Motivos:

   a. Necesidad de acomodarse a las exigencias del Derecho europeo

   b. Poner coto a la "huida del derecho administrativo" al Derecho privado → utilización de personificaciones instrumentales de Derecho privado por las AAPP.

   Sin embargo, SÁNCHEZ MORÓN detecta un cierto "retorno del Derecho Administrativo" en legislación reciente.

   Ej:

   - *2007 Ley de Contratos del Sector Público* sustituye a la Ley de Contratos de las AAPP de 1995.

Poder Adjudicador: incluye todas aquellas entidades, cualquiera que sea su forma de personificación, que hayan sido "*creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil*" y en los cuales exista alguna forma de control público efectivo en los términos fijados por el Derecho de la UE.

- *Ley de transparencia 19/2013* cuyo ámbito de aplicación se define con la máxima amplitud.
- *Ley de Régimen Jurídico del Sector Público* sustituye a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c. Las Leyes últimamente mencionadas **conviven** con otras Leyes administrativas cuyo ámbito de aplicación se sigue definiendo en términos más limitados.

d. El ámbito de aplicación del DA debe plantearse de manera singularizada para cada materia.

   i. **Ámbito más aplio - *Sector Público***

   ii. **Situaciones intermedias - *concepto de "poder adjudicador"*** → entidades con forma jurídico-privada sólo si cumplen determinados requisitos

   iii. **Ámbito más estricto - *Administración Pública***

e. **Complejidad**: *la determinación de la normativa aplicable a los concretos supuestos de hecho que pueden plantearse resulta en ocasiones una labor árdua y no exenta de dificultades para el operador jurídico.*

▼ **¿La administración pública puede usar otro derecho que no sea el DA?**

Sí, la "huida del derecho administrativo".

La "huida del derecho administrativo"

Hay un fenómeno que es el de la **"huida del derecho administrativo"** → tendencia de las administraciones públicas a intentar escapar de la aplicación del derecho administrativo. Es decir, siempre que puede, la administración intenta actuar con arreglo al derecho privado y no al derecho administrativo. Y ésto pasa porque *el derecho administrativo pone trabas, es un derecho muy rígido*, un derecho que dificulta la **agilidad** de la administración.

El empleado público quiere tomar decisiones **sin procedimientos** que le dificulten la decisión. Y el *derecho civil se basa en la autonomía de la voluntad*. Es mucho

más ágil, no está sujeto a tantos procedimientos, requisitos. El DA es un derecho claramente procedimentalizado.

Otra razón es que los **controles económicos** del derecho civil son mucho menos restrictivos que los del derecho administrativo.

Entonces, se recurre a la **creación de personas jurídicas sujetas al derecho privado**. Por esto proliferan tanto las **sociedades mercantiles públicas** y las **entidades públicas empresariales** (EPS) (son cosas distintas). Ej: en muchos municipios el suministro de agua lo que hace el ayuntamiento es crear una SA o una entidad pública empresarial para prestar el servicio de abastecimiento de agua de modo que la prestación del servicio pasa a estar sujeta al ámbito del derecho privado.

Ésto es una patología? Es ilegal? No, siempre en cuando se haga bien. El propio ordenamiento jurídico ya admite que las admin. creen EPEs y SAs. **Es legítimo**. Lo que no es legítimo es que esas personificaciones sujetas al derecho privado ejerzan potestades administrativas (públicas). Y allí dónde las puedan ejercer, deberán hacerlo aplicando derecho administrativo. Estas entidades de derecho privado pueden ejercer potestades administrativas, pero cuando lo hagan deben aplicar derecho administrativo por mucho que sean personas jurídico-privadas.

Ej: si no pagamos el recibo del agua, nos embargarán. La administración siempre cobra. Pero a la hora de embargar-me tiene que aplicar derecho administrativo por mucho que sea una EPE.

*Cuando se ejerzan potestades adminstrativas tienen que estar sujetas al DA.

▼ **¿Pueden instancias privadas ejercer potestades administrativas?**

Sí, siempre se rijan por el DA.

Y también hay **INSTANCIAS PRIVADAS** que aplican DA. Siempre que una persona jurídico-privada ejerce potestades administrativas debe hacerlo aplicando DA. Ej: **sociedad mercantil** es una persona de Derecho privado. Pero cuando ejerce potestades administrativas se somete al derecho privado. Un **concesionario de la administración** cuando ejerce potestades admin. se rige por Derecho público. También los colegios profesionales (**colegio de abogados**) - al fin y al cabo cumplen funciones privadas. Pero también funciones públicas ej: ordena el turno de oficio, y ejerce la potestad disciplinaria sobre los abogados. Las normas sobre estos 2 ámbitos están regidos por DA. Por lo tanto, una instáncia que en su origen es privado, cuando ejerce potestades admin. se rige por DA.